



我国个人敏感信息界定之构想

胡文涛*

内容提要 个人敏感信息在我国规范性文件中已有体现,但规定间存在一定冲突。公众对不同信息敏感度存在差异,通知同意规则也已引发诸多质疑,我国未来个人信息保护法有必要对个人信息进行类型化区分,以实现信息保护与信息利用的更好平衡。敏感信息界定方法,宜在现行定义加列举的基础上,增加信息处理的情境和目的为考量因素。具体种类方面,应结合对泄露该信息是否会导致重大伤害、给信息主体带来伤害的几率、社会大多数人对某类信息的敏感度三个因素的综合考量,立足于中国国情,回应技术的发展,将健康信息、性生活和性取向、身份证件号码、金融信息、政治意见、通讯信息、基因信息、生物特征信息和精确地理位置列为个人敏感信息。

关键词 个人敏感信息 个人信息安全规范 个人信息保护

随着信息技术的发展,大数据时代的到来,近年来,我国个人信息泄露事件频发且波及范围极广,54%的网民认为个人信息泄露情况严重,84%的网民曾亲身感受到因个人信息泄露带来的不良影响,网民权益损失平均一年逾千亿元。^①对此,有学者认为是敏感数据的所有权和使用权没有明确界定导致的恶性循环,^②有学者提出应“强化个人敏感隐私信息”保护,^③对个人敏感信息进行特别规定或分类保护,^④但也有学者认为“个人信息保护法中不宜采用敏感个人信息概念”,^⑤妥当的立法体例是“在各类个人信

* 上海海事大学法学院副教授,法学博士。本文系国家社科基金项目“大数据时代金融隐私权保护法律问题研究”(项目批准号:15BFX113)的阶段性成果。

① 参见中国互联网协会、12321网络不良与垃圾信息举报受理中心:《〈2016中国网民权益保护调查报告〉(摘要)》,载网经社网:<http://b2b.toocle.com/detail-6418179.html>,最后访问时间:2018年8月23日。

② 参见朱琳:《个人信息“裸奔”,谁的眼泪在飞》,载《法制日报》2017年11月14日第11版。

③ 参见张新宝:《从隐私到个人信息:利益再衡量的理论与制度安排》,载《中国法学》2015年第3期。

④ 参见鞠晔、王平:《云计算背景下欧盟消费者个人敏感数据的法律保护》,载《法学杂志》2014年第8期;曹杰、王晶:《跨境数据流动规则分析——以欧美隐私盾协议为视角》,载《国际经贸探索》2017年第1期;刘德良则主张根据与人格利益有无直接关系而区分个人信息并给予不同的法律保护,参见刘德良:《个人信息保护与中国立法的选择》,载陈海帆、赵国强主编:《个人资料的法律保护:放眼中国内地、香港、澳门及台湾》,社会科学文献出版社2014年版,第44-45页。

⑤ 周汉华:《个人信息保护法及立法研究报告》,法律出版社2006年版,第79-80页。

息单行法律法规中予以特别规定”。^⑥

考虑到目前关于个人敏感信息的界定问题,切合时代发展又符合中国实际的深入研究尚有不足,^⑦本文拟通过考察我国现行个人敏感信息的规定及问题,分析区分个人敏感信息和一般信息的必要性和可行性,讨论个人敏感信息的界定方法和确立个人敏感信息的考虑因素,并进而提出我国个人敏感信息的具体种类设想,力图为我国个人信息保护立法提供一定参考。

一、问题的提起:我国现行法对个人敏感信息之规定及困境

目前,我国对个人信息保护的法律法规散见于不同部门发布的规范性文件。法律和行政法规层面主要有《民法总则》《网络安全法》《刑法》《侵权责任法》《消费者权益保护法》《商业银行法》《居民身份证法》《执业医师法》《关于加强网络信息保护的決定》以及国务院先后于2010年和2013年发布的《互联网信息服务管理办法》《征信业管理条例》等;部门规章方面,主要有《电信和互联网用户个人信息保护规定》(国家工业和信息化部2013年发布)和《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》(中国人民银行2005年发布)等;国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会分别于2012年和2017年发布了关于个人信息保护的两大国家标准:《信息安全技术公共及商用服务信息系统个人信息保护指南》(以下简称《个人信息保护指南》)和《信息安全技术 个人信息安全规范》(以下简称《个人信息安全规范》)等;此外,较多的司法解释针对个人信息侵权和犯罪案件处理作出了规定,如《关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》(最高人民法院2014年发布,以下简称《网络侵权责任规定》)、《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》(最高人民法院、最高人民检察院2017年发布,以下简称《侵犯个人信息刑事案件的解释》)以及《关于依法惩处侵害公民个人信息犯罪活动的通知》(最高人民法院、最高人民检察院、公安部2013年发布,以下简称《惩处侵害个人信息犯罪的通知》)等。考察这些规范性文件对个人敏感信息的规定发现,现有立法规定呈现出如下特点及问题。

(一)个人敏感信息与个人一般信息的分类已有体现

2017年出台的《民法总则》宣称个人信息受法律保护,个人信息的获取需依法取得,^⑧为个人信息提供了根本性的法律保障。但该法并未标明何谓“个人信息”,何谓“依法取得”。对于前者,《网络安全法》第76条在法律层面上作出了界定,认为“个人

⑥ 张鹏:《论敏感个人信息在个人征信中的运用》,载《苏州大学学报》2012年第3期。

⑦ 主要法学论著有,汪全胜、方利平:《个人敏感信息的法律规制探析》,载《现代情报》2010年第5期;汤敏:《论同意在个人信息处理中的作用——基于个人敏感信息和个人一般信息的二维视角》,载《天府论坛》2018年第2期;前引④,鞠晔、王平文;前引⑤,周汉华书,第75-80页等。

⑧ 《民法总则》第111条规定:“自然人的个人信息受法律保护。任何组织和个人需要获取他人个人信息的,应当依法取得并确保信息安全,不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。”

信息”是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息,包括但不限于自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息等,《电信和互联网用户个人信息保护规定》也作出了类似规定。^⑨

对于个人信息的类型,《网络安全法》等法律没有进一步的区分。而作为行政法规的《征信业管理条例》中的第13条和第14条虽未采用个人一般信息与敏感信息的区分性称谓,但对其采集作差别性要求,即对个人一般信息允许经同意而采集,而对第14条规定的特殊信息禁止采集,隐含着对个人敏感信息的特殊保护。^⑩ 最高人民法院2016年发布的《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》(以下简称《互联网公布裁判文书的规定》)明确要求人民法院在互联网公布裁判文书时,应当删除自然人的家庭住址、通讯方式等个人信息,^⑪意味着加强对某些个人信息的特别保护;而《侵犯个人信息刑事案件的解释》区分“非法获取、出售或者提供”不同种类信息的数量,作为是否认定为《刑法》第253条之一规定的“情节严重”的条件。^⑫ 其隐含之意是:“非法获取、出售或者提供”的信息种类不同对个人危害程度存在差异,因而需要打击的力度也应有差别。此外,《网络侵权规定》《互联网公布裁判文书的规定》《惩处侵害个人信息犯罪的通知》对个人隐私和个人其他信息也采用了区分性规定,^⑬这虽反映出其对个人信息和个人隐私本质差别未完全准确把握(如个人信息与个人隐私究竟是交叉关系还是并列关系,具体需如何划分等),但亦隐含对个人信息进行区分之意。

作为我国首部个人信息保护国家标准,2012年发布的《个人信息保护指南》明确规定“个人信息可以分为个人敏感信息和个人一般信息,”并对个人敏感信息予以定义和

⑨ 《电信和互联网用户个人信息保护规定》第4条规定:“本规定所称用户个人信息,是指电信业务经营者和互联网信息服务提供者在提供服务的过程中收集的用户姓名、出生日期、身份证件号码、住址、电话号码、账号和密码等能够单独或者与其他信息结合识别用户的信息以及用户使用服务的时间、地点等信息。”

⑩ 《征信业管理条例》第13条规定:“采集个人信息应当经信息主体本人同意,未经本人同意不得采集。”第14条规定:“禁止征信机构采集个人的宗教信仰、基因、指纹、血型、疾病和病史信息以及法律、行政法规规定禁止采集的其他个人信息。”

⑪ 《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》第10条规定:“人民法院在互联网公布裁判文书时,应当删除下列信息:(一)自然人的家庭住址、通讯方式、身份证号码、银行账号、健康状况、车牌号码、动产或不动产权属证书编号等个人信息。”

⑫ 《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第5条规定:“非法获取、出售或者提供公民个人信息,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第253条之一规定的‘情节严重’:……(三)非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的;(四)非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的;(五)非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的。”

⑬ 《关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第12条规定:“公开自然人基因信息、病历资料、健康检查资料、犯罪记录、家庭住址、私人活动等个人隐私和其他个人信息,造成他人损害,被侵权人请求其承担侵权责任的,人民法院应予支持。”《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》第10条(一),同前引⑪;第10条(四)规定:“家事、人格权益等纠纷中涉及个人隐私的信息。”《关于依法惩处侵害公民个人信息犯罪活动的通知》“二”规定:“公民个人信息包括公民的姓名、年龄、有效证件号码、婚姻状况、工作单位、学历、履历、家庭住址、电话号码等能够识别公民个人身份或者涉及公民个人隐私的信息、数据资料。”

列举。^⑭ 指南虽仅为指导性技术文件,并非规范性法律文件,但在我国开启了明定个人敏感信息之先河。2017年发布的《个人信息安全规范》未明确区分个人一般信息和个人敏感信息,但也从国家标准层面界定和列举了个人敏感信息的内涵和外延。^⑮ 该规范虽只是一份推荐性国家标准,并非法律,但在个人信息保护法缺位之际,为企业从事个人信息处理活动提供了一套相对全面而完整的行为规范,意义匪浅,后文将重点分析。

可见,虽然我国现行法律法规中对个人信息分类的规定只是依稀可见,但在国家有关部门颁布的国家标准中,个人一般信息和敏感信息的区分已十分明确。

(二) 现行法对个人敏感信息的规定存在抵牾

由于我国高位阶的法律中并未明确区分个人信息的种类,而对个人信息的分类又已体现在行政法规和其他低层次的文件中,导致法律法规和其他文件之间存在相互冲突及宽严失度之不足。

首先,这种冲突表现在法律与行政法规之间。《民法总则》并未标明何谓“依法取得”,但在此之前,《消费者权益保护法》作出了“明示”“同意”的规定;^⑯《网络安全法》则要求“明示并取得同意”;^⑰同样的规定亦见于《关于加强网络信息保护的决定》^⑱以及《电信和互联网用户个人信息保护规定》,根据这些法律规定,经营者、网络产品、服务提供者、电信业务经营者、互联网信息服务提供者等取得个人信息的基本要求是,明示收集目的并取得个人同意。而此处个人同意并没有明示与默示的区分,换言之,根据这些法律法规,只要个人同意,经营者、网络产品、服务提供者等即可以收集个人信息,无论何种信息,也无论是采用明示还是默示同意的方式。而《征信业管理条例》对个人敏感信息的采集实行的是“禁止”性规定,且没有除外条款作为缓冲,即无论个人同意与否,也无论基于何种理由,个人敏感信息均禁止收集。

其次,这种冲突体现在不同机构颁布的规范性文件中。如根据最高人民法院颁布的《互联网公布裁判文书的规定》第10条,“通讯方式”属于一般个人信息,而《个人信息安全规范》将电话号码归入个人敏感信息;又如,“宗教信仰”除在《征信业管理条例》和《个人信息保护指南》属于敏感信息外,在其他规范性文件中均未作特殊规定。

最后,这种规定的冲突甚至体现于同一机构颁布的规范性文件中。如最高人民法院颁布的《网络侵权规定》第12条区分“个人隐私”和“其他个人信息”,而《互联网公布裁判文书的规定》第10条则分为“个人信息”和“涉及个人隐私的信息”,两规定关于“个人隐私”的内涵明显不同:《网络侵权规定》的“个人隐私”包括病历资料、健康检查

^⑭ 参见《信息安全技术公共及商用服务信息系统个人信息保护指南》“3.7”。

^⑮ 参见《信息安全技术 个人信息安全规范》“3.2”。

^⑯ 《消费者权益保护法》第29条规定:“经营者收集、使用消费者个人信息,应当……明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经消费者同意。”

^⑰ 《网络安全法》第22条第3款规定:“网络产品、服务具有收集用户信息功能的,其提供者应当向用户明示并取得同意……”

^⑱ 《关于加强网络信息保护的决定》规定:“二、网络服务提供者和其他企业事业单位在业务活动中收集、使用公民个人电子信息,应当……经被收集者同意,不得违反法律、法规的规定和双方的约定收集、使用信息。”

资料、家庭住址,而这几项内容与《互联网公布裁判文书的规定》的“个人信息”部分重合,但是,《互联网公布裁判文书的规定》的“个人隐私”则又另有所指,与“个人信息”并列成为法院公布时应予删除的信息。可见,上述两文件中重合的个人信息部分,被排除在《互联网公布裁判文书的规定》规定的个人隐私之外。此外,同属于国家标准的《个人信息保护指南》和《个人信息安全规范》虽然都对个人敏感信息作了规定,但其定义尤其是种类均差异甚巨。

综上所述,我国现行规范性文件关于个人敏感信息的规定凸显的问题在于:首先,高位阶的法律未充分认识到个人信息区分的必要性。就法律层面而言,对个人信息的重要程度、可能对个人造成的危害程度未能充分认识并有效区分,且对个人信息的收集采取过于宽松的态度,而某些行政法规又采取过于僵硬的措施,导致法律与行政法规间适用的冲突;其次,个人敏感信息的界定标准缺乏共识。我国低层次的规范性文件已经对个人信息作出区分,但由于对如何认定个人敏感信息、个人敏感信息究竟应包括哪些种类等问题缺乏共识,导致不同机构甚至同一机构规定出现混乱和抵牾。这些问题的存在,凸显我国高位阶的统一立法对个人信息予以区分、并对个人敏感信息作出明确界定的迫切性。

二、未来我国立法的基本设想: 区分个人敏感信息与个人一般信息

虽然“软法”中已有体现,但正如上文所述,目前我国法律法规并未对个人信息作种类的划分。我国学者、人大代表起草的“个人信息保护法”建议稿中也未作区分。^① 2017年11月全国人大法工委民法室制定的《人格权编草案(室内稿)》第6章“隐私权和个人信息”以8个条文规定了个人信息的保护,同样未区分个人信息的种类,^②并引发学者批评。^③ 有学者认为,域外立法中的敏感信息概念含义非常广泛,而我国国情不同,没有必要一定在个人信息保护法中规定敏感个人信息,完全可以通过单行立法的方式解决。^④ 笔者认为,在个人信息保护法中明确界定个人敏感信息,有助于降低乃至解决前

^① 参见齐爱民:《中华人民共和国个人信息保护法示范法草案学者建议稿》,载《河北法学》2005年第6期;参见前引⑤,周汉华书,第1-27页;吴晓灵等全国人大代表于2017年3月提交的《中华人民共和国个人信息保护法(草案)》,参见《中华人民共和国个人信息保护法(草案)2017版》,载搜狐网:http://www.sohu.com/a/203902011_500652,最后访问时间:2018年8月23日。

^② 参见孙宪忠:《关于〈人格权编(草案)〉(2017年11月15日法工委民法室室内稿)》的评审意见之一,载天津市宁河区人民法院网:<http://tjnhfy.chinacourt.org/article/detail/2018/02/id/3202332.shtml>,最后访问时间:2018年8月23日。

^③ 叶名怡认为“个人信息的缺漏更多,比如说没有规定敏感信息和一般信息在法律适用效果上的区别”,参见《社科院“民法典分编草案(室内稿)座谈会”实录》,载搜狐网:http://www.sohu.com/a/220558816_662101,最后访问时间:2018年8月23日。

^④ 参见前引⑤,周汉华书,第79页;前引⑥,张鹏文。

述政出多门产生的混乱、重复和抵牾之弊。且在统一界定的基础上,再由单行立法针对具体的敏感信息作详细或特殊的规定,能更有效地为个人敏感信息提供不同层次的保护。因此,建议未来我国个人信息保护法区分个人一般信息和敏感信息并对个人敏感信息予以特别保护。下文对区分的必要性和可行性予以分析。

(一)从个人信息敏感度视角看个人信息区分的必要性

20世纪70年代起,随着信息通讯技术的发展,个人信息处理方式发生急剧变化,为避免非法储存、不准确储存以及滥用个人信息损害个人利益,许多国家开始了个人信息保护的立法实践,并大体形成了两种立法模式:制定《个人信息保护法》的欧盟统一立法模式和将个人信息保护纳入隐私权保护体系的美国分散立法模式。

在我国,对个人信息保护的讨论和立法均晚于隐私权。就理论研究而言,中国知网的检索结果显示,关于“隐私”的论文最早发表于1981年,而关于“个人信息”的论文最早发表于1989年。^{②③}立法上,早在1988年,最高人民法院的相关司法解释就将侵害隐私纳入了侵害名誉权的范畴,2009年颁布的《侵权责任法》第2条又第一次在法律层面上明文规定了隐私权,而在2012年《关于加强网络信息保护的决定》出台之前,我国并没有个人信息保护的专门立法。此后,在法律中直接规定个人信息保护条款的趋势才日益明显,如2013年修改的《消费者权益保护法》第14条增加规定消费者“享有个人信息依法得到保护的权利”;《民法总则》分别于第110条和第111条对隐私权和个人信息的保护作出规定,从而在我国形成“二元制”的保护模式。

对于个人信息与隐私的关系,主流意见认为两者是交叉关系、相互存在一定的重合,^{②④}该观点最终也为全国人大法工委接受。^{②⑤}但也有学者认为,将“空间隐私”纳入隐私权保护的并不妥当,真正属于隐私范畴的应该只是我国通说的“信息隐私”。^{②⑥}笔者认为,个人空间的保护涉及的不仅是财产权,因此,赞同用“三分法”来区分隐私与个人信息,即分为纯粹的个人隐私、隐私性信息、纯粹的个人敏感信息。^{②⑦}而且,笔者进一步提出,对个人信息应主要根据信息敏感度等因素的差异,区分为敏感信息和一般信息。

敏感在英文中的含义丰富,根据梅里亚姆—韦伯斯特词典的解释,其中之一的含义是“高度反应或易受影响:例如容易受到伤害或造成损失:特别是精神上的伤害”。^{②⑧}可见,所谓“敏感”是对特定的因素具有高反应度,个人信息的敏感度描述的是个人信息对

②③ 参见中国知网:<http://www.law.cnki.net/>,最后访问时间:2018年8月17日。

②④ 参见前引③,张新宝文;王利明:《论个人信息权在人格权法中的地位》,载《苏州大学学报》2012年第6期;陈甦主编:《民法总则评注》,法律出版社2017年版,第789页。

②⑤ 参见石宏主编:《中华人民共和国民法总则:条文说明、立法理由及相关规定》,北京大学出版社2017年版,第263页。

②⑥ 参见刘金瑞:《个人信息与权利配置——个人信息自决权的反思和出路》,法律出版社2017年版,第166页。

②⑦ 参见李永军:《论〈民法总则〉中个人隐私与信息的“二元制”保护及请求权基础》,载《浙江工商大学学报》2017年第3期。

②⑧ ‘highly responsive or susceptible: such as a (1): easily hurt or damaged; especially: easily hurt emotionally’, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/sensitive>, (Last visited on Aug 22, 2018).

信息主体造成伤害或影响的程度。

个人信息是通过一定形式,尤其是电子数据表现出来的个人情况,现代社会中,个人的几乎所有情况都可能成为个人信息。出于个人生活、工作和人际交往的需要,人们必须提供姓名、电话号码、教育背景、职业乃至银行账户等诸多信息。而不能不承认的是,受道德、习俗等多重因素影响,某些个人信息,如健康信息、性生活、金融信息等的泄露对个人尊严或财产会造成严重影响,而另一些信息的传播对个人生活影响则相对较弱。英国信息保护署组织的电话访谈显示,公众对不同信息的“极其敏感度”(Extremely Sensitive)存在从 70.5% 到 17.4% 的差异。^{②9} 我国大多数公众也认为信息存在敏感与一般之分,在一项对“不同的个人信息具有的敏感度的区别”的调查中,主张“非常有区别”和“有区别”的分别占 56.12% 和 22.45%,而“没有区别”和“完全无区别”只占 5.10% 和 4.08%。^{③0}

至于某些敏感信息需特别保护的原因,正如台湾学者所言:“DNA、病历、前科等,即使不公开亦不直接影响该个人一般社会生活之经营。公共性低、私密性高之资料,且此类资料多属个人不欲为人所知之私生活领域资料,如他人得滥行搜集或利用,将造成该个人精神不安或被贴标签而致人格受损。”^{③1} 欧洲委员会则更加明确地指出:“由于敏感数据是个人数据中风险因素较大的部分,它的公开和传播不仅带来狭义的隐私权侵害,而且还带来政治或社会上的歧视,妨害人的尊严和基本权利,因此需采取比一般个人数据更加严格的安全措施。”^{③2} 可见,某些信息具有高敏感度,一旦泄露可能导致人格受损、引发歧视和妨害人格尊严,是需对其进行特殊保护的根本原因。只有将这些信息与一般个人信息予以区分,给其贴上敏感信息的预警标签,从信息处理的实体和程序要求上提供更加严格的保护,才能够全面提升对敏感信息的保护水平。

也有学者认为,“敏感”一词的主观性太强,其敏感度完全可能因不同的主体而完全不同,因而反对区分个人敏感信息和一般信息。^{③3} 对此,笔者认为,敏感度确实因人而异,但若联系后文将述的伤害程度、结合对大众对个人信息敏感度的调查统计数据,并在此基础上再确定主要的个人敏感信息种类,应能消除分类的相对性和不确定性,而这也正是本文的意旨所在。

(二) 从企业经济成本视角看个人信息区分的必要性

网络信息化社会的个人信息存在两种最直接的利用价值:商业利用价值和公共管理价值。因此,适应时代的个人信息保护法一方面应加强对个人信息的保护,另一方面也要为个人信息的收集、处理、传输等提供适当的法律框架,以使个人信息得到合理开

^{②9} See Karen McCullagh, *Data Sensitivity: Proposals for Resolving the Conundrum*, 2 J Int'l Com & Tech 196 (2007).

^{③0} 参见刘雅琦:《基于敏感度分级的个人信息开发利用保障体系研究》,武汉大学出版社 2015 年版,第 65 页。

^{③1} 范姜真嫩:《个人资料保护法关于“个人资料”保护范围之检讨》,载前引④,陈海帆、赵国强主编书,第 60 页。

^{③2} 欧洲委员会《2012 年〈个人数据处理中的个人保护公约〉评析。三、(二)“敏感数据的特殊风险控制原则”》,载高富平主编:《个人数据保护和利用国际规则:源流与趋势》,法律出版社 2016 年版,第 65 页。

^{③3} 参见前引④,刘德良文,第 29 页。

发和利用,实现其内在价值。^{③④}换言之,个人信息保护法需要在个人信息保护和个人信息的利用、信息自由之间获得平衡。

考察个人信息保护制度的发展历程,不同国家和地区制度设计的主线是个人信息自主模式的发展,^{③⑤}强调信息主体积极参与、控制并决定个人资料的使用范围及其正确性、完整性,如美国学者 Charles Fried 认为,信息隐私的理念不应只局限于不让他人取得我们的个人信息,而应扩张到由我们控制自己的个人信息。^{③⑥}这种信息自主模式的实现倚重于“通知—同意”的程序性机制设计:信息收集前通知信息主体,信息主体同意后方可收集和使用信息。我国的法律规定亦大体如此,对于信息的取得,从《消费者权益保护法》到《网络安全法》均构筑了以同意规则为中心的信息保护模式。

但是,信息自主模式和同意规则在近些年受到诸多质疑,美国学者 Daniel J. Solove 认为,信息自主模式承担了超出了其能力的任务,一些认知的难题削弱了人们对隐私的自我管理;此外,隐私也不仅关乎某个人,还具有社会功能。^{③⑦}我国也有学者认为,“同意不应是个人信息处理的正当性基础”,^{③⑧}更有学者尖锐地指出,冗长而复杂的隐私条款,不加区分的同意,一方面增加了消费者的同意成本,造成“实践中适用同意规则流于形式”,^{③⑨}使得“用户权利几近架空”,因而“无法为公民隐私提供实质性保障”^{④⑩};另一方面,也提高了互联网企业的合规成本,给企业造成沉重负担,且严重阻碍了数据流通,制约了企业对数据价值的开发利用。

与之相比,《个人信息保护指南》与《个人信息安全规范》的规定则相对合理。其中,《个人信息保护指南》区分个人信息并明确采取不同的同意规则,规定收集个人一般信息时,可采取默许同意的办法,而收集个人敏感信息,则需明示同意;《个人信息安全规范》规定对个人信息的收集需“授权同意”,联系其要求收集敏感信息的“明示同意”,^{④⑪}此处规定应该是认可收集一般信息的默示同意。由是观之,两者的基本观点一致,即在对个人信息作层级区分的基础上,对个人敏感信息和一般信息的收集分别采取明示和默示同意的规则。对个人信息予以区分、并对不同信息收集予以区别式对待,或许无法根治同意规则的痼疾,但至少能缓和僵硬的明示同意带来的弊端,在一定程度上降低企业的合规成本,并同时发挥保护个人敏感信息的作用,更好地平衡个人信息保护与利用的关系。

对于区分个人敏感信息和一般信息,也有学者批评到:在大数据时代,几乎所有种

^{③④} 参见张新宝:《隐私权的法律保护》(第2版),群众出版社2004年版,第139页。

^{③⑤} 参见前引^{②⑥},刘金瑞书,第33页。

^{③⑥} See Charles Fried, *Privacy*, 77 Yale L. J. 475 (1968).

^{③⑦} See Daniel J. Solove, *Introduction: Privacy Self-Management and the Consent Dilemma*, 126 Harv. L. Rev. 1880-1881 (2013).

^{③⑧} 任龙龙:《论同意不是个人信息处理的正当性基础》,载《政治与法律》2016年第1期。

^{③⑨} 金耀:《消费者个人信息保护规则之检讨与重塑——以隐私控制理论为基础》,载《浙江社会科学》2017年第11期。

^{④⑩} 范为:《大数据时代个人信息保护的路径重构》,载《环球法律评论》2016年第5期。

^{④⑪} 参见《信息安全技术 个人信息安全规范》“5.3”“5.5”。

类的数据均可导出特殊数据,特别保护只会增加管制成本、阻碍企业数据分析,因此,费力区分和保护终是徒劳无功。^②对此观点,笔者认为,个人信息保护法立足于人格尊严和自由,人格尊严的保护属于立法追求的目的价值,而个人信息的利用属立法追求的工具价值,相较之下,目的价值应优先于工具价值。况且,个人信息和隐私的保护一直与技术的发展紧密相关,虽然以现代信息科技的发展水平,即使是对数据匿名处理仍能复原识别个人,但这些技术的发展恰恰突显出了个人信息保护的迫切性,因此,大数据时代并没有削弱个人敏感信息保护的基础价值,而我们更应在保护的种类和方法上予以变更,以回应时代的发展。

(三)从国际国内立法经验看个人信息区分的可行性

在制定个人信息保护法的过程中,许多国家和国际组织尝试界定敏感信息。研究表明,1970年德国黑森邦的个人资料保护法和1973年瑞典资料法中就曾出现敏感资料的概念。^③法国1978年的法律也对种族、政见等敏感资料作出了更严格的处理条件规定。^④但一般认为敏感信息的概念滥觞于20世纪80年代的国际公约。欧洲理事会于1981年颁布了《有关个人数据自动化处理的个人保护协定》(Convention for the Protection of Individuals With Regard to Automatic Processing of Personal Data,以下简称《欧盟个资公约》),其中对特殊类型数据的自动化处理作出了特别规定,成为首次明确界定个人敏感信息的国际公约。^⑤联合国于1990年发布《规范电脑化个人数据文件指导原则》(Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files),该原则虽未使用“敏感性”或“特殊”等词,但在其第5条“非歧视原则”(Principle of non-discrimination)中指出,对某些“可能引起非法或恣意歧视的资料”禁止收集。1995年出台的欧盟《个人数据保护指令》(Directive 95/46/EC,以下简称《欧盟个资指令》)第8条明确了特殊数据的种类,并对其处理作严格限制。该规定成为了“欧盟数据保护政策的基石”,^⑥由于指令要求成员国国内法遵行,受其约束,欧盟各国均立法规定了敏感信息。欧盟以外的其他国家和地区,如澳大利亚、韩国、我国台湾地区等,也仿效欧盟的立法作出类似规定。美国对个人敏感信息的规定原本散布于联邦多种立法中,而2015年提交的《消费者隐私保护法案》(Consumer Privacy Protection Act of 2015)中规定了敏感个人可识别信息(Sensitive Personally Identifiable Information),并将保障其安全作为法案的主旨。^⑦

^② See Tal Z. Zarsky, *Incompatible: The GDPR in the Age of Big Data*, 47 Seton Hall L. Rev. 1013-1014 (2017).

^③ See Karen McCullagh, *supra* note 29, 190.

^④ See Gloria Gonzalez Fuster, *The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU*, at 63-65 (Springer, 2014).

^⑤ 参见《欧盟个资公约》第6条。2012年,《欧盟个资公约》被修改为《个人数据处理中的个人保护公约》(Convention for the Protection of Individuals With Regard to the Processing of Personal Data),第6条明确将标题由“数据的特殊类型”变更为“敏感数据的处理”。

^⑥ Z. Zarsky, *supra* note 42, 1012.

^⑦ See ‘Consumer Privacy Protection Act of 2015’, ‘SEC. 3. Definitions. (10)’.

各国历史发展、文化背景、意识形态互不相同,决定了不同国家国民对信息的敏感度不尽一致。但是,越来越多的国家或地区在定位于保护个人尊严、基本人权和自由的个人信息保护法中,对事关个人尊严、容易引发歧视的敏感信息作出特殊保护的规定。而这些立法关于个人敏感信息的种类及其认定的方法的规定,为我国立法提供了可资借鉴的经验。

在我国学者组织的“对个人信息分级进行公开和利用的态度”调查中,“非常赞同”和“赞同”该方案的分别占41.84%和22.45%,而“反对”和“完全反对”该方案的只分别占12.24%和6.12%。^{④8}赞同的总占比达64.29%,远远高于反对的18.36%。为回应现实的要求,我国现行法规、司法解释已朝分类立法迈开步伐,并逐渐积累立法经验。如前所述,我国《征信业管理条例》对不同信息采取区分保护措施,司法解释《网络侵权责任规定》《互联网公布裁判文书的规定》《惩处侵害个人信息犯罪的通知》均已从名称上对个人隐私信息和个人其他信息作出了区分规定。并且,这种区分已在司法实践中得到体现,如北京市第一中级人民法院在“庞理鹏与北京趣拿信息技术有限公司等隐私权纠纷案”的审理中,^{④9}详尽分析了“姓名和手机号”究竟是隐私信息还是一般信息;最高人民法院认为该判决是“可推广的审判经验”,并将该案作为第一批涉互联网典型案例予以发布。^{⑤0}

对我国未来区分立法更具直接参考价值的是《个人信息保护指南》和《个人信息安全规范》等国家标准。从2012年发布的《个人信息保护指南》到2017年的《个人信息安全规范》,标准日臻全面且贴合中国实际,且这两个国家标准对个人敏感信息和个人一般信息作出了明确区分,其就个人敏感信息的种类、收集要求、保护的技术支撑等多方面的规定使我国未来的立法更具可行性。

三、个人敏感信息界定方法的构想： 法律列举辅之综合考量

(一)个人敏感信息的界定方法

发端于20世纪70、80年代的欧洲个人数据保护法以及美国的隐私权保护法律定位于保护个人尊严和自由,“在保护基本人权与自由的共同理念下,就会形成共同普遍的个人信息保护共同原则并被各国所接受进而内化为各国的国内立法。”^{⑤1}截至2017

^{④8} 参见前引^{⑤0},刘雅琦书,第65-66页。

^{④9} 参见北京市第一中级人民法院(2017)京01民终509号民事判决书。

^{⑤0} 参见人民法院新闻传媒总社:“最高人民法院发布第一批涉互联网典型案例”,载最高人民法院网:<http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-112611.html>,最后访问时间:2018年8月18日。

^{⑤1} 高富平:《个人数据保护权非个人数据权(代序言)》,载前引^{⑤2},高富平主编书,第3页。

年,全球已有 120 个国家制定了个人资料保护法或隐私法,以保护国民的个人信息。^②综观国际条约和不同国家及地区的个人信息保护立法,个人敏感信息的界定方法大体可分为法律列举模式和综合考量模式两种。

1. 法律列举模式

法律列举模式是根据个人信息的内容(Content)对敏感信息的种类予以列举,主张基于某些资料的性质(Nature),如“可对基本自由和隐私造成侵害”“引发歧视”“很可能伤害到个人之权利与利益”等,^③立法须禁止对其收集、处理和利用。英国 1998 年“资料保护法指南”即明确指出,由于有关此类事项的信息可能招致歧视,并可能属于私人的性质,因此需要比其他个人数据更细心地加以对待。数据的性质是决定采取何种保护才是适合的一个因素。^④目前,法律列举模式是个人敏感信息立法的主流,《欧盟个资公约》《欧盟个资指令》以及英国、德国、比利时、丹麦、法国、瑞典、俄罗斯、澳大利亚、韩国、我国台湾地区等国家和地区的立法均采用此方法界定敏感信息,2015 年美国《消费者隐私保护法案》对敏感个人可识别信息亦采用了列举的方式。

2. 综合考量模式

综合考量模式反对基于信息的性质界定个人敏感信息,主张综合数据处理的情境、目的等因素来判断信息是否敏感。其中,依对数据处理综合考虑因素的不同,又有“情境说”和“目的说”两种不同的主张。

“情境说”主张个人信息是否敏感并不取决于内容,而是根据其情境(Context)。“情境说”在奥地利和德国悠久的历史,受该说影响,经合组织在 1980 年制定《OECD 个资原则》时,最终舍弃了列举个人敏感信息的方法。^⑤《欧盟个资公约》虽然以内容明确界定个人敏感信息,但其解释报告也承认,通常情况,资料处理会对人产生伤害,并不是基于该资料之内容,而是该资料的使用情境。^⑥此外,美国 2012 年《网络环境下消费者的数据隐私保护》也体现了依情境评估信息敏感性的理念,而 2015 年《消费者隐私权利法案》的政府讨论稿(Administration Discussion Draft: Consumer Privacy Bill of Rights Act of 2015)则更是极力倡导情境理念。^⑦

^② See Graham Greenleaf, Global Data Privacy Laws 2017: 120 National Data Privacy Laws, Including Indonesia and Turkey, at <https://ssrn.com/abstract=2993035>, http://www.sohu.com/a/203902011_500652 (Last visited on July 15, 2018).

^③ 参见《欧盟个资指令》立法说明第 33 项;联合国 1990 年发布的《规范电脑化个人资料文件指导原则》第 5 条;《欧盟个资原则》第 6 条的解释报告等。

^④ See (UK) Guide to Data Protection (1998), at <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/> (Last visited on June 30, 2017).

^⑤ 当时,有人提出任何数据都可能在特定的语境下或因不同的用途变为“私人的”或“敏感的”。See ‘Detailed Comments: Paragraph 7: Collection Limitation Principle’, in ‘Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data’.

^⑥ See Council of Europe, Article 6-Special categories of data, on CETS 108-Explanatory Report to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, at <https://rm.coe.int/16800ca434> (Last visited on Sept 20, 2017).

^⑦ See Administration Discussion Draft: Consumer Privacy Bill of Rights Act of 2015, SEC. 4. Definitions[k].

“目的说”主张,考虑敏感性时应关注处理个人数据的目的,即使是相同的资料,在不同情况下也会产生不同的敏感性,均系因个人使用的“态度”(Attitude)而定,而不是因资料自身的本质发生了变化。⁵⁸例如,警察有权透过DNA推断种族信息,然而,授权一个保安根据此类信息决定某人能否进入一幢大楼则不合适。又如购物网站汇集消费者购买各类宗教图书的数据,若目的在于揭露消费者的宗教信仰偏好,则该数据属于个人敏感信息;若目的在于统计各类购书比例,则不属于敏感信息。澳大利亚信息委员会发布的“隐私原则”明列了个人敏感信息的种类,并规定“生物特征信息”“被用于特定目的”时也属于敏感信息。⁵⁹欧盟2016年公布了《关于在个人数据处理方面对自然人保护和此类数据自由流动的第2016/679号条例》(The EU General Data Protection Regulation,下文简称《一般数据保护条例》),其中第9条明确规定“禁止以识别自然人身份为目的对个人基因数据、生物特征数据的处理”,可见,目的说已体现在对特殊数据的判定中。

(二)两种界定模式的评析与我国宜采纳的方法

法律列举模式被普遍采用,其优点在于信息控制人或信息主体能迅速根据法律规定判断哪些信息被“禁止收集、处理和利用”或须遵循更为严格的信息保护原则,有利于信息得到切实保护;其缺点在于信息的内容与形式都会随科技发展、社会变迁而发生变化,并且,由法律规定和判断信息是否敏感的立法方式并未考虑信息主体的个人意见和感受,既可能保护过度又可能保护不足。⁶⁰正因如此,早有学者指出,欧盟立法中的个人敏感信息种类过时、在决定数据处理条件时失效,并进而提出了参考目的说和情境说的解决方案。⁶¹

Nissenbaum教授是“情境完整性理论”的提出者。他将对隐私的足够保护和特殊情境规范联系起来,认为个人信息收集时的情境应得到充分尊重,后续传播和利用不得超出最初的情境。他跳出对个人信息的公开/非公开、敏感/非敏感信息的刻板二分法,指出信息敏感与否需充分考虑所处情境才能作出判断。⁶²被誉为欧洲现代信息隐私法之父的Simitis教授更直言,敏感不应被认为是一个先验(Priori)概念,相反,任何个人数据,依其处理的目的和环境都可能是敏感的,因此,所有的数据都应该依据背景和环境作出评估,进而决定其使用。数据控制者及潜在接收者的特殊兴趣,数据收集的目的,数据的处理条件及可能的结果都是考虑因素,应将所有这些因素加以综合考虑,进而辨别是否敏感以及其敏感的程度,而不仅仅是从表面上看数据。⁶³但是,此类依情境、目的

⁵⁸ See Karen McCullagh, *supra* note 29, 199.

⁵⁹ See *Sensitive information*, Australian Privacy Principles, at <https://www.oaic.gov.au/privacy-law/privacy-act/australian-privacy-principles> (Last visited on Sept 28, 2017).

⁶⁰ 参见蔡秉锜:《敏感性个人资料保护之研究》,台湾大学2012年硕士学位论文,第52页。

⁶¹ See Karen McCullagh, *supra* note 29, 190.

⁶² See Helen Nissenbaum, *Privacy as Contextual Integrity*, 79 Wash. L. Rev. 119 (2004).

⁶³ See Spiros Simitis, *Revisiting Sensitive Data*, at <https://rm.coe.int/09000016806845af> (Last visited on Aug 28, 2018).

等综合衡量的方法过于弹性,更多强调主观判断,如果将判断个人敏感信息的工作完全交由不同的主管机关或法院个案判定,敏感信息的定义必然发生歧义,反而不利于个人敏感信息的保护。因此,笔者主张法律列举模式应成为未来我国个人信息保护法界定敏感信息的基本方法。

我国已颁布的国家标准《个人信息保护指南》和《个人信息安全规范》对个人敏感信息采取的是定义加列举的方式,即先依据个人信息的内容或性质定义敏感信息,进而对其种类予以列举。前者认为个人敏感信息是“一旦遭到泄露或修改,会对标识的个人信息主体造成不良影响的个人信息”,^④后者将之界定为“一旦泄露、非法提供或滥用可能危害人身和财产安全,极易导致个人名誉、身心健康受到损害或歧视性待遇的个人信息。”^⑤两相比较,后者更为准确,前者所言“不良影响”过于宽泛,而后者先通过“极易”作程度的限制,再强调后果是“导致个人名誉、身心健康受到损害或歧视性待遇”,含义更为清晰。这是需要肯定的,也是值得未来我国个人信息保护法继续采纳的方法。

但是,对于个人敏感信息的界定,上述两个国家标准均未吸收域外综合考量模式的成果,如果说《个人信息保护指南》还通过“各行业个人敏感信息的具体内容根据接受服务的个人信息主体意愿和各自业务特点确定”的条文留下解释空间的话,^⑥在此方面,《个人信息安全规范》的规定则全无通过情境、目的等综合判断个人信息是否敏感的适用余地,不能不说留有遗憾。

事实上,综合判断之情境说已在我国司法实践中欣然可见,在前述“庞理鹏与北京趣拿信息技术有限公司等隐私权纠纷”案中,^⑦北京市第一中级人民法院首先认定,姓名、电话号码及行程安排等事项属于个人信息;进而根据《网络侵权规定》认定行程安排属于隐私信息;最后指出:姓名和手机号不构成隐私信息,但当姓名、手机号和庞理鹏的行程信息(隐私信息)结合在一起时,结合之后的整体信息也因包含了隐私信息(行程信息)而整体上成为隐私信息。本案中,法官关于姓名和手机号构成隐私信息的推断就运用了情境分析的方法,充分考虑了预订机票中的特殊情境,从而作出了姓名、手机号属于隐私信息的明智判断。未来,我国的个人信息保护法可借鉴域外综合考量模式作为补充,规定:在具体个案中,即使不是法律明文列举的个人敏感信息,也可依信息处理的特殊情境和目的,由特定机构(比如法院)来判断究竟是否属于敏感信息。

四、个人敏感信息的种类设想: 以敏感度为重点考量因素

(一)域外个人敏感信息的主要种类及新发展

^④ 《信息安全技术公共及商用服务信息系统个人信息保护指南》“3.7”。

^⑤ 《信息安全技术 个人信息安全规范》“3.2”。

^⑥ 《信息安全技术公共及商用服务信息系统个人信息保护指南》“3.7”。

^⑦ 参见前引^④。

1. 域外个人敏感信息的传统种类

在域外立法中,《欧盟个资公约》将种族、政治主张、宗教或其他信仰以及与健康、性生活或刑事判决有关的个人数据列为敏感信息;《欧盟个资指令》增加了“工会会员”,但无“刑事判决”内容,^⑧且这一规定日后成为了欧盟及其他许多国家和地区立法的基础样板;美国缺乏专门的个人信息保护法,根据美国学者依分散的立法对个人敏感信息作出的总结,其主要种类有健康信息、金融信息、关乎个人安全的信息(包括家庭地址、工作地址、甚至电话号码、Email 网址等在线联系信息等在内)、犯罪记录、教育信息、有关儿童的信息、公务记录等。^⑨

2. 域外个人敏感信息种类的新发展

近年来,随着互联网应用和数字化进程的加快,特别是计算机通讯技术以及生物科技发展日新月异,民众和国际组织对敏感信息的认知发生变化,各国对个人敏感信息种类的界定也出现了新的动向,一些原本不属敏感的信息逐渐步入敏感信息系列,主要体现在基因信息、生物特征信息、金融信息等方面。

首先,基因和生物特征信息被较普遍地归为个人敏感信息。基因信息是自然人先天继承和后天获得的有关基因特征的信息,生物特征信息是通过自然人的身体、生理或行为进行特定技术处理而得到的个人信息。随着技术的发展,这些信息因其独特的价值而被广泛挖掘利用,也因此被归入了敏感信息的范畴。例如,在英国信息保护署2006年组织的电话访谈中,生物特征信息和基因信息分别位居第2和第3位,被民众认为是次于金融信息的个人敏感信息;^⑩受制于《欧盟个资指令》对敏感信息种类的限制,卢森堡、荷兰将基因纳入健康信息,葡萄牙将基因纳入有关健康、性生活的数据予以列举保护;^⑪欧洲委员会在2012年通过的《个人数据处理中的个人保护公约》第6条将“基因数据”和“可以识别个人身份的生物特征数据”归入敏感数据;2015年美国《消费者隐私保护法案》将包括面相(faceprint)、指纹(fingerprint)、声音(voice print)、视网膜(a retina)、虹膜(iris image)等在内的生物特征识别数据列为敏感个人可识别信息;^⑫2016年5月,欧盟公布《一般数据保护条例》,其中第9条明令禁止对以确定自然人特定身份为目的的基因数据和生物特征的数据处理。

其次,金融信息(Financial Information,也译为财务信息)被较广泛地视为一种敏感信息。金融信息与个人人格尊严关系并不密切,但由于它的丧失容易导致经济损害,因此在英国信息保护署2006年组织的电话访谈中,位居极度敏感信息的首位。^⑬此外,美

⑧ 《欧盟个资公约》第6条;《欧盟个资指令》第8条。

⑨ See Paul Ohm, *Sensitive Information*, 88 S. Cal. L. Rev. 1150-1160 (2015).

⑩ See Karen McCullagh, *supra* note 29, 195.

⑪ See Douwe Korff, *EC Study on Implementation of Data Protection Directive* (2002), at 82, at: <http://ssrn.com/abstract=1287667> (Last visited on Aug 23, 2018).

⑫ *Supra* note 47.

⑬ See Karen McCullagh, *supra* note 29, 200.

国基于消费者金融信息关涉隐私的认识,于1999年出台“金融服务现代化法”促使金融机构保护消费者的金融信息。2015年美国《消费者隐私保护法案》更是明确将金融账号、信用卡或借记卡号列为敏感个人可识别信息。^⑦日本虽然未将金融信息列入敏感信息,但对信用信息、信用卡密码等带来二次被害发生可能性高的信息给予特别保护。^⑧

最后,精确地理位置、网页浏览信息被一些国家纳入个人敏感信息范畴。精确地理位置是通过通讯设备收集的特定个人在特定时间所在位置数据。随着移动互联网的发展,对个人位置数据的不当收集和滥用可能危及个人安全,为此,一些国家和地区立法对其进行规制:韩国早在2005年就制定了专门的《位置信息保护与使用法》,旨在防止位置信息泄露、被滥用和误用;^⑨2015年美国《消费者隐私保护法案》规定的敏感个人可识别信息包括了精确地理位置。2016年12月,美国联邦通信委员会公布“宽带和其他电信服务中用户隐私保护规则”,以促进宽带接入服务(Broadband Internet Access Services,简称BIAS)提供商和其他电信运营商加强用户信息和隐私保护。根据该规则,通信交流信息、网页浏览信息、App使用历史等均属于敏感信息,BIAS提供商只有在消费者明确同意(Opt-in)的前提下方可使用和共享。^⑩尽管由于监管权之争,该规则遭到废除,^⑪但其确立的基本原则和个人敏感信息的种类仍具有前瞻性和启发意义。

3. 确立个人敏感信息的考虑因素

美国学者 Paul Ohm 在对欧美个人敏感信息清单作出详尽考察之后,归纳出确立个人敏感信息的四大因素:伤害的可能性、引发伤害的几率、信任关系的存在、是否属多数人关心的风险,并提出了“多重因素检测”的观点。^⑫参考此观点,笔者提出如下判定个人敏感信息的考虑因素。

(1)泄露该信息是否会导致重大伤害。如前所述,所谓“敏感”是对于特定的因素具有高度的反应或受到影响,信息的敏感度指信息内容的泄露是否容易对他人造成伤害或影响。一般来说,个人信息被泄露的后果有生活秩序被打乱、个人安全受到威胁、名誉受到影响、经济利益被侵害等,但不同信息的泄露所引发的后果存在差异,即存在不同的敏感度。根据前述列举模式界定个人敏感信息的基本观点,基于某些信息的性质,其一旦被公开即可对个人隐私、权利、利益造成伤害,因此,对这些高敏感度的信息必须给予更严格地保护。健康信息、性生活、性取向信息、犯罪记录、金融信息即属于一旦泄露即易对人格尊严、财产导致重大伤害的信息,因而被许多国家和地区列为个人敏

^⑦ *Supra* note 47.

^⑧ 参见日本厚生劳动省、经济产业省:“個人情報保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン”,“2-2-3-2. 安全管理措置”第2-2-3-2条“安全处置措施”。

^⑨ 参见王融:《大数据时代:数据保护与流动规则》,中国工信出版集团、人民邮电出版社2017年版,第221页。

^⑩ See ‘Protecting the Privacy of Customers of Broadband and Other Telecommunications Services’, at <https://www.fcc.gov/fdsys/pkg/FR-2016-12-02/pdf/2016-28006.pdf> (Last visited on Aug 23, 2018).

^⑪ 参见沈玲:《特朗普时代美国信息通信业核心制度的变革走向》,载《信息安全与信息保密》2017年第7期。

^⑫ See Paul Ohm, *supra* note 69, 1161.

感信息。

(2)泄露该信息给信息主体带来伤害的几率是否非常大。有些信息的泄露并不一定导致重大伤害,但有些则可能引发歧视,有些甚至可能因为滥用而间接引发伤害,如果引发这些不良后果的几率已经非常高,则应考虑立法对其进行规制。例如,许多国家对人种、政治主张、信仰、工会成员资格等信息的保护系出于对防止歧视的考虑;又如,由于通讯和生物技术的进步增加了伤害的手段、扩大了伤害的范围,引发了许多过去没有的、伤害个人的风险,因此,基因信息、生物特征信息、精确地理位置、网页浏览信息也逐渐被纳入个人敏感信息。

(3)特定社会大多数人对某类信息的敏感度。确定个人敏感信息意在保护人格尊严、自由,但敏感是非常主观的概念,伤害(特别是对人格尊严伤害)的体验也因人而异。有着不同文化传统、社会习俗、历史经历的国家 and 地区之间,甚至同一国家和地区不同的人之间,对此的感受都大相径庭。但是,当一个社会相当比例的人都认为某些信息特别重要,泄露这些信息将极大伤害个体时(换言之,当一个社会多数人对某些信息具有高敏感度时),立法者则应考虑将这些信息作为敏感信息加以保护。考察域外个人敏感信息的法律规定可以发现:一方面,敏感信息种类的不同反映出一般公众观念的差异,例如,由于欧洲国家在二战中深受纳粹践踏人权之苦,欧盟比美国更加重视对人种、政治主张、宗教、工会等信息的保护;另一方面,由于人类情感具有相通性,不同国家在个人敏感信息种类界定上又具有趋同性。

(二)我国个人敏感信息种类之设想

1. 对个人敏感信息调查问卷的数据分析

2016年7月至2018年8月,笔者曾组织在上海、江苏、浙江、安徽、河北、山东、河南、广东、山西、湖南等地通过问卷调查的方式进行了个人信息敏感度调查。本次调查共发放问卷620份,回收584份,回收率94.19%,其中有效问卷582份,有效率99.66%。根据有效回收的582份问卷,得出表1数据。接受调查的人员中,男性265人,占总数的45.53%;女性317人,占总数的54.47%。97.94%为18岁以上的成年人,92.27%的受访者几乎每天上网,其中,经常居住地为城镇者占总数的84.36%;农村者占15.64%;高中以下、专科、本科、研究生及以上者分别占总数的9.62%、9.28%、39.69%和41.41%;受访者的职业中,学生、企业职员、公务员或事业单位人员、农民、自由职业者和其他分别占总数的48.11%、26.63%、10.14%、1.89%、7.39%和5.84%。调查结果如下:

表1:个人敏感信息问卷调查结果

	个人通讯 资料	金融信息	刑事记录	医疗信息	就业履历	网络浏览 信息	性生活
极度敏感	68.21%	59.28%	46.22%	41.41%	39.86%	36.43%	35.06%
完全不敏感	5.84%	11.00%	13.06%	9.45%	12.03%	22.51%	12.20%

	教育程度	基因信息	政治意见	政党或组织 会员资格	宗教或哲 学信仰	种族或 民族起源	工会会员 资格
极度敏感	30.93%	30.41%	23.71%	10.82%	9.97%	9.79%	5.84%
完全不敏感	23.54%	29.73%	32.30%	36.60%	62.71%	49.48%	60.31%

本问卷旨在调查公众对不同信息的敏感程度,设计的选项包括《欧盟个资公约》和《欧盟个资指令》纳入的7种敏感信息及未被纳入的7种其他较常见信息,尽管该调查存在样本数量有限、地域分布不够广泛、职业代表性不够全面等局限性,但由于统计结果真实地反映了我国经常上网的成年人对个人敏感信息的想法,因而结果仍具有一定参考价值。调查结果反映出如下现象:

首先,对于个人信息的敏感度,“极度敏感”高于“完全不敏感”,前者总数为2611次,后者为2215次,表明公众对个人信息保护整体比较关注,如85.22%的受访者十分担心或担心上网时个人信息被泄露;其次,在欧盟公约和指令列入的7种事项中,除对刑事记录、性生活、健康(医疗)信息“极度敏感”超过30%之外,对工会会员、人种和宗教信仰等信息“极度敏感”的均在10%以下,而“完全不敏感”者接近或超过50%,分列不敏感事项前列,反映出我国民众与欧盟民众信息敏感度的差异;再次,个人通讯信息和金融信息分列“极度敏感”信息的首位和次位,且占比远超50%,显示出我国民众对通讯秘密和金融信息的高度关注。这两类信息应作为重点保护对象;最后,对网络浏览信息这一较新型的信息类型,认为其“极度敏感”者已达36.39%,主要原因在于依此能够挖掘出信息主体的其他敏感信息,如何对其加以保护值得立法者深思。

2. 我国现行规定的个人敏感信息

表 2:依我国现行规定应予特殊处理的个人信息

种 类	健康生 理信息	基因	身份证 号码	银行账号 (银行卡 信息)	指纹	家庭 住址	通讯方式 (手机号 码)	行踪轨 迹信息	通信内容 (记录)	征信 信息	财产 信息
出现次数	5	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
来 源	①②③④⑥	①④⑤	②⑤⑥	②⑥⑦	①⑤	②④	②⑤	③⑥	③⑥	③⑥	③⑥
种 类	住宿 信息	交易 信息	宗教 信仰	血型	车牌 号码	动产或不 动产权属 证书编号	犯罪 记录	种族	政治 观点	个人生 物识别 信息	儿童个 人信息
出现次数	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
来 源	③⑥	③⑥	①⑤	①	②	②	④	⑤	⑤	⑥	⑥

(注:1. 标号代表:①为《征信业管理条例》,②为《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》,③为《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》,④为《关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》,⑤为《信息安全技术公共及商用服务信息系统个人信息保护指南》,⑥为《信息安全技术 个人信息安全规范》,⑦为《非银行支付机构网络支付业务管理办法》;

2. 健康生理信息不同表述还有:疾病和病史信息、健康状况、病历资料、健康检查资料;3. 儿童个人信息在《信息安全技术 个人信息安全规范》中的完整表述是:14周岁以下(含)儿童的个人信息。)

特殊处理的方式包括禁止采集、采集时适用更严格的要求、网上公布时应予删除等。从表2可见,依我国现行规定,需特殊处理的个人信息总计达22种之多,规定频次最高的是健康生理信息、其次是基因、再次是身份证号码和银行账号。上述信息类型的规定既体现了《欧盟个资指令》的影响,同时也回应了通讯技术以及生物科技的发展,但在内容整合方面不尽如人意,且因颁布部门不同而生冲突,对此前已述及、不再赘述。

近年颁布《个人信息保护指南》和《个人信息安全规范》两个规范性文件对个人敏感信息进行了明确列举。前者认为个人敏感信息“可以包括身份证号码、手机号码、种族、政治观点、宗教信仰、基因、指纹等”^⑩,后者明确包括“身份证件号码、个人生物识别信息、银行账号、通信记录和内容、财产信息、征信信息、行踪轨迹、住宿信息、健康生理信息、交易信息,14周岁以下(含)儿童的个人信息等。”^⑪对比两者的规定,前者借鉴欧盟色彩非常明显;而后者较多地回应了现代技术发展的需要,但在内容整合上依然存在不足,如将金融财产信息分为三项;而诸如性生活等与个人尊严密切相关的事项却未列入正文,仅在资料性附录中提及;此外,对交易信息应否纳入其中尚待斟酌;等等。

3. 对我国个人敏感信息种类的具体构想

基于上述列举的确立个人敏感信息的三个考量因素,笔者将个人敏感信息定义为“一旦泄露或滥用,极易危及人身、财产安全或导致人格尊严受到损害、歧视性待遇的个人信息”。结合上文对相关立法和学说的分析及调查收集的数据,笔者建议将以下个人信息列为个人敏感信息:(1)健康信息;(2)性生活和性取向;(3)身份证件号码;(4)金融信息;(5)政治意见;(6)通讯信息;(7)基因信息;(8)生物特征信息;(9)精确地理位置。主要理由如下:

第(1)、(2)类信息属于高私密性而低公共性的信息,为人格领域中的私密领域,其实质内容涉及人格尊严的核心,^⑫一旦泄露即会伤及人格或引发歧视。此外,从立法和实践来看,健康信息在我国多部规范性文件中出现或明确列为隐私;^⑬在学者组织的调查中,“疾病和病史”与“身体形态、基因”等以68.1%的比例高居“不应当被征信系统收集”的信息首位,^⑭笔者组织的调查结果也显示其具备作为个人敏感信息的广泛民意。性生活和性取向一直被认为是属于私密性极强的个人隐私,一旦泄露即会严重危及个人尊严,应列为个人敏感信息自不待言。

第(3)、(4)类信息本身均无关人格尊严,但被泄露后若被不当利用,将给信息主体带来伤害的几率极大。通过身份证信息不仅可以直接识别特定的个体,而且可以把个

⑩ 《信息安全技术公共及商用服务信息系统个人信息保护指南》“3.7”。

⑪ 《信息安全技术 个人信息安全规范》“3.2”注1。

⑫ 参见王泽鉴:《人格权法:法释义学、比较法、案例研究》,北京大学出版社2013年版,第198页;杨芳:《隐私权保护与个人信息保护法——对个人信息保护立法潮流的反思》,法律出版社2016年版,第16页。

⑬ 参见表2,另见《侵权责任法》第62条、《执业医师法》第22条等。

⑭ 参见白云:《个人信用信息法律保护研究》,法律出版社2013年版,第152页。

人的房地产、存款、股票基金账户、纳税、医疗、出行、住宿等其他敏感和非敏感信息连接起来,全方位展现个人生活,^⑤极易严重侵害个人隐私;而金融信息被滥用则可能给信息主体带来巨大财产损失。在一项学者组织的敏感度调查中,非常同意身份证号码“很敏感”的人数占 57.14%,不同意其“敏感”的仅占 1.02%,而存贷款信息更是位列高敏感度之首。^⑥在笔者组织的调查中,认为金融信息“极度敏感”的高达 59.28%,位居第二,充分显示出这些信息具备纳入个人敏感信息的强大民意基础。

第(5)、(6)类信息满足上述三个考虑因素的第 2 项,政治意见的公开对个人乃至家庭生活、前途影响巨大,其敏感性不言自明,且已被《个人信息保护指南》列为个人敏感信息;通讯信息内含广泛的个人其他信息,包括不愿公开或公开后极可能引发伤害的敏感信息,在笔者组织的调查中位居极度敏感之首,应纳入个人敏感信息。

第(7)、(8)、(9)类信息属于随着生物技术、通讯技术的发展而产生的、一旦泄露引发伤害几率很大的信息。基因信息是自然人继承或后天获得的基因特征方面的信息,属个人信息的深层次内容,它不仅能显示该人独特的生理或健康信息(如揭示个人疾病、缺陷与基因的关系,解释个人的品格、智力等),更重要的是,基因具有种族、家族相关性,因此,基因信息的泄露还可能导致对其个人乃至其家族的歧视。^⑦生物特征信息是对人的身体或行为特征经特定技术处理后得到的信息,基于该信息不仅能识别自然人的身份,而且可从事其他越来越广泛的个性服务,如利用指纹、面部图像开启手机、银行账号等,若不加以特别保护,可能引发不可预测的伤害。精确地理位置是通过通信设备收集的特定个人在特定时间所在的位置的信息,对个人位置信息的不当收集甚至滥用不仅可能危及个人人身安全,而且可能危及信息主体的家人和财产的安全。这几类信息已在近年颁布的法规和国家标准中得到不同程度重视,有必要被立法列为个人敏感信息。

此外,“法律既为社会力,则社会变迁,法现象不能不与之俱变。”^⑧现代科技发展日新月异,一日千里,技术的发展已导致并可能继续引发新的、重大而实在的伤害风险,因此,未来的个人信息保护法在列举上述个人敏感信息的同时,还应给科技发展可能带来的敏感信息种类变化留下空间。

结 语

我国个人信息保护的规定散见于不同位阶的规范性文件中,个人信息的种类区分

⑤ 参见程啸:《侵权责任法》,法律出版社 2015 年版,第 165 页。

⑥ 参见前引⑤,刘雅琦书,第 95-97 页。

⑦ 参见刘仁忠、代薇:《基因隐私的伦理和法律规范》,载《自然辩证法研究》2004 年第 9 期。

⑧ [日]穗积陈重:《法律进化论》,黄尊三等译,中国政法大学出版社 1997 年版,第 53 页。

在《个人信息安全规范》等国家标准中已得到明确体现,但分散的规定相互冲突。无论是从个人信息敏感度视角还是从企业成本视角考虑,未来我国个人信息保护法都有必要对个人信息进行类型化区分,以减少目前因政出多门而产生的混乱、重复和抵牾之弊,并且,在为敏感信息提供更严格保护的同时,更好地平衡信息保护和信息自由的关系。关于个人敏感信息的界定方法,可继续采取定义并列举的基本方式,将个人敏感信息定义为“一旦泄露或滥用,极易危及人身、财产安全或导致人格尊严受到损害、歧视性待遇的个人信息”;此外,建议将综合信息处理的情境和目的作为认定敏感信息的补充,在个案中,由特定机构来判断某个人信息是否为敏感信息。关于个人敏感信息的具体种类,建议结合泄露该信息是否会导致重大伤害、给信息主体带来伤害的几率、社会大多数人对某类信息的敏感度三个考量因素,将健康信息、性生活和性取向、身份证件号码、金融信息、政治意见、通讯信息、基因信息、生物特征信息和精确地理位置列为个人敏感信息,同时,考虑到未来技术的发展变化,为一些特殊信息的保护预留空间。

Abstract: Personal sensitive information has been reflected in China's normative documents, but there is no categorization of personal information in the law. The public's sensitivity to personal information is different, and meanwhile informed consent doctrine faces an infinite challenge in the big data era. Therefore, sensitive information should be defined and stringently protected in the Individual's Information Protection law of China. As for defining sensitive information, based on nature of information and list in law, context and purpose should also be considered. As for the specific types, three factors should be considered: whether the leakage of information may cause serious harm, the probability of harm to information subjects, and the sensitivity of most people in society to information. Therefore, the following information should be defined as sensitive information: health information, sexual life and sexual orientation, criminal records, political opinions, identification number, communication information, financial information, genetic information, biometric information and geographic location.

(责任编辑:王莉萍)